

1501063-03.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011). "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501063-03.2021.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501063-03.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2185564/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 18955195 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1878/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2185564 - 02º D.P. PIRACICABA, 1878/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RODRIGUES PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Processo nº 1501063-03

VISTOS.

BRUNO RODRIGUES PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de julho de 2021, por volta de 22h00, na Avenida Miguel Caparroz, nesta cidade e comarca, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 158 (cento e cinquenta e oito) tubos plásticos contendo cocaína, com o peso líquido de 39,5g (trinta e nove gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares receberam informações sobre o tráfico de drogas que estaria ocorrendo no local dos fatos. Foram ao ponto informado e observaram o réu em típica atividade de comércio ilícito de entorpecentes: viram que ele, por algumas vezes, entregou e recebeu algo de motoristas de veículos automotores. Viram, ainda, que ele foi até um canteiro central e, entre algumas folhas, pegou alguma coisa de uma sacola preta e colocou dentro da pochete que trazia consigo.

Fizeram, então, a abordagem do réu e encontraram em poder dele, na pochete, 06 (seis) microtubos verdes com cocaína, R\$ 46,00 reais e um telefone celular.

Ato contínuo, foram ao canteiro central e encontraram a sacola preta, dentro da qual apreenderam 152 (cento e cinquenta e dois) microtubos verdes contendo cocaína. Aos agentes da lei, o réu confessou que “estava na prática do tráfico”. Na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio.

Considerando as circunstâncias da prisão, a apreensão de dinheiro e de grande quantidade de entorpecente, é certo que o réu o trazia consigo, guardava e tinha em depósito com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 76/85), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 88/89). O réu foi notificado (fls. 15), constituiu Defensor (fls. 95) e apresentou defesa prévia, na qual alegou inocência e requereu a realização de exame de insanidade mental (fls. 99/101).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência e determinando-se a instauração de exame de insanidade mental (fls. 113/116). O réu foi citado (fls. 165).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns e 02 testemunhas de defesa, sendo o réu interrogado (fls. 171/172).

A pedido da Defesa (fls. 179) e com concordância do Ministério Público (fls. 187), foi deferido o aproveitamento nestes autos do laudo pericial realizado no feito nº 0000207-38.2022.8.26.0451 (fls. 188).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu fixação da pena no mínimo legal; diminuição da pena em patamar mínimo diante da semi-imputabilidade; afastamento do tráfico privilegiado em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem como pelas condições pessoais do agente, e, por fim, fixação de regime fechado (fls. 205/223).

A Defesa do réu alegou inocência pugnando por absolvição. Aduz que o réu é inimputável e necessita de tratamento médico (fls. 231/233).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, na fotografia de fls. 23, no laudo de constatação de fls. 31/33, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 110/112, segundo o qual foi detectada a presença da substância cocaína nos materiais apreendidos.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu silente (fls. 07/08).

Em Juízo, o réu disse que no dia dos fatos, saiu do serviço às 18h00 e foi para casa. Tomou banho, jantou e discutiu com sua mulher. Ela pegou seus bens e jogou para fora. Subiu na “biqueira” e trocou o celular pelas drogas. Pegou dois papeis alumínio de cocaína e o traficante iria lhe entregar mais uma porção. Estava apagando as fotos do seu celular, quando foram abordados, tanto ele quanto o menino. Falou que estava ali trocando o celular por droga. Foi levado à Delegacia, porque os policiais disseram que iriam averiguar o celular. O menino que vendeu a droga foi liberado. Lá, conversou com o Delegado e contou o ocorrido, mas os policiais apresentaram a droga. Ficou sem entender nada. Só tinha consigo 02 alumínio de cocaína e R\$ 50,00. O celular seria trocado por 03 papeis alumínio de cocaína e R\$ 50,00, mas o traficante só tinha 02 papeis de foi buscar mais um, no canteiro da avenida. Faz uso de cocaína e não conseguia ficar sem consumi-la.

Devido ao acidente, usava medicação forte e consumia drogas, por isso, tinha convulsão quase todos os dias. Não manteve contato com nenhum carro. Ficou com 02 porções e R\$ 50,00 e o celular, que estava apagando as fotos. Pegava droga ali todos os dias. Foi preso novamente no mesmo lugar, por tráfico, posteriormente, dia 08/09. Quando adolescente, também respondeu por um tráfico de drogas. Não foi internado na Fundação Casa. Comprava drogas ali todos os dias e conhecia o rapaz pelo vulgo. Usava drogas e fazia uso de medicação. Também usava álcool (fls. 171/172).

A autoria foi comprovada pelas demais provas produzidas nos autos. Vejamos. O policial militar Carlos Alberto Morasco contou que o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Várias ocorrências foram realizadas nesse local. Nesse dia, foram ao local, pararam a viatura um pouco mais para cima e desceram a rua a pé, em meio às árvores. Observaram o réu, trajando calça e blusa azul. Os carros vinham, o réu pegava o dinheiro, o motorista dava uma volta no quarteirão e, quando o motorista voltava, ele lhe entregava alguma coisa, que retirava da pochete da sua cintura. Depois, viram que o réu foi até o canteiro, retirou uma sacola preta e pegou alguma coisa dela, que colocou na pochete. Efetuaram a abordagem e, com o réu, na pochete, havia apenas drogas (06 pinos de cocaína) e dinheiro. Em meio das folhas, encontraram a sacola preta, onde havia 152 pinos de cocaína. Informalmente, o réu falou que havia amasiado há pouco tempo e, por isso, precisava de dinheiro e estava ali para a mercancia ilícita. As embalagens de todas as drogas eram iguais. Uma vez, tinha abordado o réu, mas não sabe se foi ali ou em outro local. O réu não lhe disse que estava vendendo drogas a mando de outra pessoa. Se não se engana, o réu tinha antecedente criminal, mas não o tinha prendido anteriormente (fls. 171/172).

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar William Vergo Colasam, segundo o qual estava de serviço e foram ao local, já conhecido pela prática de tráfico de drogas. Foram verificar e desembarcaram nas proximidades. Foram pelo canteiro central da avenida a pé, até perto do local, ficando no meio das árvores. Avistaram o réu, que estava com calça de moletom e blusa azul e preta. Viram que passavam carros, ele ia até o veículo, tirava algo da pochete. Isso aconteceu várias vezes. O réu ia até o veículo, recebia o pedido, recebia o dinheiro e entregava a droga. Enquanto isso, viu o réu ir até uma sacola preta e retirar alguma coisa e colocar na pochete que estava no seu corpo. Retornaram à viatura, foram até o local e abordaram o réu. Em busca pessoal, na pochete do réu, havia 06 pinos de cocaína de cor verde, um celular e R\$ 46,00 em notas diversas. No local onde observaram o réu mexer na sacola preta, conseguiu encontrá-la e lá havia mais 152 pinos de cocaína, idênticos àqueles que estava na posse do réu. O réu falou que tinha amasiado há pouco tempo, precisava de dinheiro e, por isso, estava no tráfico de drogas. Não conhecia o réu. Só o réu fazia a mercancia de drogas (fls. 171/172). Dorival Simões França contou que só soube dos fatos posteriormente. Conhece o réu há 15 anos, do trabalho. O réu trabalha com reciclagem. Não sabe se ele faz uso de drogas. O réu tem um filho e é amasiado, há 02 ou 03 anos. O réu teve um acidente com a Gareli e ficou com sequela na cabeça, usando remédio controlado. Sem o remédio, ele acaba que não escutava ninguém (fls. 171/172).

Isaías Martins de Souza asseverou que nada sabe sobre os fatos narrados na denúncia. Conhece o réu há 02 anos e meio, do trabalho. O réu trabalhava no EcoPonto, com reciclagem. O réu tem um filho e acha que é amasiado. Não sabe se ele tem envolvimento com drogas. Sabe que o réu sofreu um acidente e ficou a base de remédio, para ficar “bem da cabeça” (fls. 171/172).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, nada disse sobre os fatos. Em Juízo, afirmou que estava adquirindo drogas, em troca do seu celular. Já havia recebido 02 porções de maconha envolta em papel alumínio e R\$ 50,00 e estava aguardando mais 01 porção, quando ocorreu a abordagem. Os policiais abordaram também o traficante, mas o liberaram. Foi levado à Delegacia para averiguação do celular e lá soube das drogas apresentadas. Negou a acusação.

Os policiais militares relataram que tinham informações da existência de tráfico de

drogas na Avenida Miguel Caparroz, no bairro Água Branca. Por isso, foram até o local, desembarcaram da viatura e foram a pé até perto do local, onde ficaram observando a movimentação das pessoas. Puderam ver o réu que fazia contato com condutores de veículo, recebia deles dinheiro, o condutor dava a volta no quarteirão e, depois, recebiam algo do réu, que era retirado da pochete em sua cintura. Presenciaram várias vezes essa mesma conduta, até que o réu foi até o canteiro central da avenida, mexeu em algumas folhas e retirou do meio delas uma sacola preta, retirando algo de dentro dela e colocando na sua pochete. Em razão da suspeita de tráfico de drogas, realizaram a abordagem do réu. Em poder dele, havia 06 microtubos verdes de cocaína R\$ 46,00 e um celular. No canteiro da avenida, localizaram a sacola preta, dentro da qual havia mais 152 microtubos verdes de cocaína, semelhantes àqueles localizados na posse do réu. Informalmente, o réu confessou a prática delitiva e alegou que estava precisando de dinheiro, porque teria se amasiado com uma mulher, há pouco tempo. O policial William falou que o réu estava sozinho, na prática delitiva.

As testemunhas de defesa nada acrescentaram sobre os fatos, visto que não presenciaram a abordagem.

Com efeito, temos duas versões sobre o mesmo fato: a versão do réu, no sentido de que tinha em seu poder apenas 02 papéis de alumínio de cocaína, e a versão dos policiais militares que encontraram parte da droga na pochete que ele usava e presenciaram o réu mexendo no canteiro central, onde estava o restante da droga. Resta saber qual versão merece credibilidade.

Cotejando a prova, considerando que se os policiais não tivessem visto o réu mexendo no canteiro central não poderiam localizar o entorpecente, entendo que a palavra deles merece credibilidade. Além disso, toda a droga estava embalada da mesma forma, em microtubos de cor verde.

Por outro lado, os policiais afirmaram que viram a conduta do réu e que ele agia sozinho, de maneira que sua versão ficou isolada nos autos.

Importante mencionar que o traficante que receberia um celular em troca de droga, não entregaria a mercadoria e troco em dinheiro, antes de receber o bem, como mencionado pelo réu.

Ademais, a palavra dos agentes policiais tem validade como prova, em especial quando acobertada pelo restante da prova, como no caso dos autos, em que os policiais encontraram o restante da droga em local que viram o réu se dirigir.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CARMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em

15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Não há nos autos qualquer indicação de que os policiais tivessem interesse de prejudicar o réu e, por outro lado, se o quisesse, poderiam tê-lo feito com quantidade inferior de entorpecente.

Comprovado o envolvimento do réu com toda a droga apreendida, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância. O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, o réu aduziu que as duas porções de cocaína em papel alumínio que estavam em seu poder eram para seu próprio consumo. A prova confirma, contudo, a destinação de consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, o endereço é conhecido como ponto de venda de drogas e, por isso, os policiais militares fizeram a observação.

Durante esse período, os policiais militares verificaram o réu fazendo contato com condutores de veículos, recebendo deles dinheiro e entregando alguma coisa que pegava da pochete.

Em outro momento, os policiais viram o réu se dirigir ao canteiro central da avenida, mexer num monte de folhas, pegar uma sacola preta e retirar de dentro dela alguma coisa que colocou na sua pochete.

Em seguida, ele foi abordado e, em seu poder, havia droga embalada da mesma forma que o entorpecente que foi encontrado no lugar em que o réu mexia.

Essa conduta é típica de tráfico de drogas.

A quantidade de entorpecente (158 porções de cocaína) não é usualmente encontrada com usuários de drogas, evidenciando a intenção de mercancia ilícita.

Além da droga, com o réu, havia dinheiro trocado, cuja origem lícita não foi comprovada.

Informalmente, aos policiais, o réu confessou que estava na prática do tráfico de drogas, pois estava precisando de dinheiro.

Assim, o local da abordagem, a situação fática presenciada pelos policiais, a quantidade das drogas e sua forma de embalagem, a confissão informal; tudo revela que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno -

Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor, não sendo cabível desclassificação.

3) Da imputabilidade

De acordo com o laudo pericial de fls. fls. 191/199 o réu possui transtorno mental devido ao uso de múltiplas substâncias psicoativas, síndrome de dependência - F19.2 da CID 10, de forma que, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas não de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, o réu deve ser reconhecido como semi-imputável.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes criminais de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não pode ser aplicada. Embora primário, o réu já foi processado pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, em feito que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude local (processo nº 0005335-49.2016.8.26.0451 - certidão de fls. 36 e 38), no qual lhe foi aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida. Além disso, foi preso em 10/09/2021, dois meses e dois dias depois da prisão nestes autos, na mesma Avenida Miguel Caparros, pela prática de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado definitivamente (fls. 306 do processo nº 1501405-14.2021.8.26.0599). Demonstrou, pois, a reiteração da atividade ilícita, de forma que a redução não tem cabimento, por estar caracterizado que ele se dedica a atividades criminosas.

Com relação à existência de processo análogo na Vara da Infância e Juventude, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. SITUAÇÃO IDÔNEA A SER VALORADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA. USO NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em organização criminosa. Acrescente-se que, conforme documento de fl. 52, o réu apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância, fazendo do crime o seu meio de vida desde a adolescência" Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 588.716/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2020). V - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. VI - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no RESp n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no RESp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. VII Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 641.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). HABEAS CORPUS Nº 649808 - PR (2021/0065591-7) DECISÃO Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISSON LUCAS DE ALMEIDA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a pena do paciente em 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Neste habeas corpus, alega o impetrante que o paciente tem direito à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos legais destacando as condições pessoais do paciente. Requer, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado. É o relatório. Decido. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse contexto, passo ao exame das supostas ilegalidades apontadas pela defesa. No tocante a minorante, consta na sentença condenatória: "[...] No tocante à seara da dosimetria da pena, registre-se que o acusado não faz jus a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que há, nos autos, elementos suficientes a demonstrar que o acusado vinha se dedicando com frequência a inúmeras atividades delituosas, dentre elas o tráfico de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo, porte de arma de fogo, etc. (cf. se infere do laudo pericial de mov. 17.6 dos autos de inquérito policial, acima referenciado). Conforme admitido pelo próprio acusado, o mesmo tinha passagem recente, enquanto era adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o que reforça o entendimento de que o acusado vinha reiterando a prática de condutas delituosas diversas. Ou seja, a dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do chamado "tráfico privilegiado", que se destina apenas aos chamados "traficantes de primeira viagem", não se aplicando a criminosos contumazes ou a acusados que fazem do crime um modo de vida. A jurisprudência segue a mesma linha: [...]" (e-STJ, fls. 28-29, grifou-se). A Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos: "Consoante extrai-se da sentença, o julgador escorreitamente fundamentou a negativa de aplicação do chamado tráfico privilegiado, no fato de que, as provas convergiram no sentido de que o réu não estava envolvido unicamente na traficância, mas também em delitos de diversas naturezas, como o fornecimento de arma de fogo. Por importante, consigno o contido no Laudo Pericial nº 58.754/2014 efetuado no aparelho celular apreendido com o réu (mov. 17.6-IP): [...] Destarte, verifica-se que há provas suficientes do envolvimento do réu em atividades criminosas, não perfazendo, desta feita, os requisitos necessários para a concessão da benesse pleiteada. Somente a título de informação, consigne-se que o réu possui passagem pela Vara da Infância, sendo que, à época do presente feito, estava com apenas 18 (dezoito) anos, o que denota que, com a maioridade, permaneceu atuante na esfera criminal. Quanto ao pedido de alteração de regime para o aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tem-se que, uma vez mantido o quantum fixado pelo Juízo sentenciante, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão, deve permanecer inalterado o regime semiaberto aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, letra b do Código Penal, bem como a impossibilidade de determinação da reprimenda substitutiva, porquanto, não cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal" (e-STJ, fls. 75-79, grifou-se). A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no Resp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que ficou evidente o envolvimento do paciente com atividades criminosas, destacando inclusive sua passagem pela vara da infância e juventude pelo ato infracional análogo ao porte de arma de fogo, não deixando dúvida de seu envolvimento na seara criminosa. Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (HC 441.815/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,

QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018; HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017).

Vale anotar que "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020). Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator (STJ - HC: 649808 PR 2021/0065591-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no Resp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - Ilicitude da prova. Inocorrência. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 tijolo de maconha com peso líquido de 469,6 gramas), além de dinheiro e faca com resquícios de droga - Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento - Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos patamares - Atenuante da menoridade relativa inócua (Súmula nº 231 do STJ) - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Apelante que ostenta diversos atos infracionais pretéritos, um deles equiparado ao tráfico e praticado na mesma localidade. Precedentes do STJ - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1518652-88.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021).

Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Validade dos depoimentos policiais - Condenação mantida. Pena-base - Quantidades, diversidade e natureza das drogas apreendidas que autorizam a exasperação na fase inicial da dosimetria - Fração consentânea - Ato infracional a ser sopesado na fase destinada à análise da aplicação da benesse da lei especial, sob pena de inaceitável 'bis in idem'. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - Envolvimento pretérito do réu, quando menor de idade, na mercancia ilícita, sendo claro indicativo de sua dedicação exclusiva à narcotraficância - Processo em andamento - Claro indicativo da dedicação do réu a atividade criminosa - Benesse da lei especial - Aplicação - Impossibilidade - Precedente do C. STJ. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos - Peculiaridades do caso que não a recomendam, certo o alto poder viciante das drogas apreendidas. Regime prisional fechado - Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, diversas as naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a comprovada dedicação do réu à ilícita atividade. Apelo defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1502334-

58.2020.8.26.0542; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021).

Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recursos defensivo e ministerial - Absolvição não acolhida - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 - Impossibilidade - Conjunto probatório apto à manutenção da condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicado em Primeiro Grau - Insurgência ministerial acolhida - Réu que se dedica às atividades criminosas - Anotações de atos infracionais suficiente a afastar o tráfico privilegiado - Precedentes do C. STJ - Reprimenda alterada - Regime fechado correto e mantido - Substituição penal impossível - Apelo defensivo desprovido e recurso ministerial acolhido. (TJSP; Apelação Criminal 1501239-90.2019.8.26.0618; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caçapava - Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes que demonstra dedicação a atividade criminosa e impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15094837720208260228 SP 1509483-77.2020.8.26.0228, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 26/02/2021, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS - COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO - PENAS ALTERADAS - RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA - A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15009278420198260628 SP 1500927-84.2019.8.26.0628, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 23/09/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO (COCAÍNA) ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME MAIS BRANDO IMPOSSIBILIDADE CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO CONDENAÇÃO BEM LANÇADA PENA FIXADA COM CRITÉRIO CONFISSÃO QUANTO AO TRÁFICO RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA REGIME FECHADO NECESSÁRIO RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 15000354720198260315 SP 1500035-47.2019.8.26.0315, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 10/12/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/12/2019).

Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Circunstâncias do episódio que positivavam a traficância - Condenação mantida. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - Envolvimento pretérito do réu, quando menor de idade, na criminalidade, sendo claro indicativo de sua dedicação a atividade criminosa - Benesse da lei especial - Afastamento - Impossibilidade, haja vista a resignação ministerial. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos - Peculiaridades do caso que não a recomendam. Regime prisional fechado - Subsistência - Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de droga, cuja notória nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu ao ofício criminoso, com envolvimento pretérito, quando menor de idade, em práticas análogas a crime. Apelo defensivo improvido. (TJ-SP - APR: 15001570820198260591 SP 1500157-08.2019.8.26.0591, Relator: Mauricio Valala, Data de Julgamento: 24/11/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/11/2020)

A discussão apresentada neste momento é com relação ao quantum de diminuição da pena pela responsabilidade diminuída, para o caso sob exame.

O artigo 26, parágrafo único, do Código Penal prevê que em casos de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a pena pode ser reduzida de um a dois terços.

O patamar da redução deve ser apreciado de acordo com o grau da perturbação mental, de forma que quanto maior a perturbação, maior será a redução e quanto menor a perturbação, menor será a redução.

É esse o entendimento sedimentado na jurisprudência:

(...) A diminuição da pena em razão da semi-imputabilidade deve considerar o grau de perturbação da saúde mental do réu, avaliando-se a extensão de seu entendimento. Reconhecida pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do réu era reduzida, tendo em vista o seu elevado grau de discernimento, embora fosse usuário de drogas, mostra-se correta a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 26, parágrafo único, do Código Penal. Precedentes. (...) (STJ - HC 306.918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, devemos verificar qual é o grau da perturbação apresentada pelo réu, no momento da prática delitiva.

O réu referiu ao perito que faz uso de drogas desde os 14 anos de idade. Afirmou que aos 16 anos de idade foi pego com drogas, foi encaminhado para delegacia e liberado no mesmo dia. A partir dos 17 "pegou firme" no consumo. Não conseguiu mais parar (fls. 192).

Em interrogatório, o réu conseguiu fornecer elementos de defesa que indicam plena capacidade de raciocínio, na medida em que justificou que havia saído de casa porque tinha brigado com a esposa e, por isso, foi para a "biqueira" e trocou o celular pelas drogas. Pegou dois papéis alumínio de cocaína e o traficante iria lhe entregar mais uma porção. Estava apagando as fotos do seu celular, quando foram abordados, tanto ele quanto o menino. Falou que estava ali trocando o celular por droga.

Nota-se, portanto, que o réu conseguiu elaborar com habilidade sua defesa pessoal, mostrando grau de discernimento.

E esse entendimento, concretamente visualizado durante a ação penal, é compatível com a aplicação da redução mínima.

Nesse sentido, já se manifestou o superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. LATROCÍNIO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR MÁXIMO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A via estreita do habeas corpus não se presta para reavaliar o quantum de redução escolhido na incidência da minorante prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Caso em que as instâncias ordinárias, a partir das conclusões emanadas da prova pericial produzida e do exame do comportamento do réu - que demonstrou possuir "concatenação perfeita de idéias e evidenciou raciocínio lógico, a ponto de apresentar defesa pessoal bem estruturada" -, justificaram, devidamente, a redução da pena pela semi-imputabilidade em sua fração mínima, conclusão cuja revisão perpassa pela incursão em aspectos fático-probatórios, medida inviável na via mandamental. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 181.574/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015 - grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ELEVADO GRAU DE DISCERNIMENTO DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Sendo reconhecida pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do réu era reduzida, tendo em vista o seu elevado grau de discernimento, embora fosse usuário

de drogas, mostra-se correta a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 18.937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012).

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA INFERIOR À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. SEMI-IMPUTABILIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO. (...) 11. Se foi reconhecido pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do paciente consistia em uma plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e uma parcial capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, mostra-se fundamentada a redução da pena em 1/3, não sendo cabível a aplicação da fração máxima prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 12. Ordem denegada. (STJ - HC 135.604/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011).

Assim fundamentado, a semi-imputabilidade fará com que a pena seja diminuída em um terço: reclusão de 03 anos e 04 meses e 333 dias-multa.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos. Ademais, a medida socioeducativa aplicada anteriormente não foi suficiente para afastar o réu da prática delitiva e ele demonstrou que outro regime de pena não o impedirá de manter-se nesse trabalho espúrio.

Pena final: reclusão de 03 anos e 04 meses, em regime fechado, e 333 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR BRUNO RODRIGUES PINTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 03 anos e 04 meses, em regime fechado, e 333 dias-multa, diária mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. É que a quantidade de droga apreendida em sua guarda, somada ao fato de que já possuía relação com o tráfico de drogas quando adolescente indicam que tem envolvimento constante com esse delito. Assim, não é adequada a substituição.

O réu está em liberdade e assim poderá permanecer caso deseje recorrer desta sentença.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 70) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu a gratuidade processual.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA